

1500045-84.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... colaboração, como informante, com grupo para a prática do tráfico, conforme descritos na denúncia - Delito subsidiário que prevalece quando não demonstrados os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico - Desclassificação de rigor - Pena fixada no piso legal - Cabimento do regime inicial aberto e da substituição da pena - Preliminar rejeitada e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500045-84.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500045-84.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007051/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 15573955 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 70/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2007051 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ PAULO DE ALVARENGA MOREIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

LUIZ PAULO DE ALVARENGA MOREIRA, FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA E SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 35 caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal e WESLEY HENRIQUE MARTINS DA SILVA REGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Consta que, no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 07 horas, na Rua Prefeito

Osório da Cunha Lara Neto, n.º 50, Pinus do Iriguassu I, nesta cidade e Comarca de Caçapava, WESLEY HENRIQUE MARTINS DA SILVA REGO, supostamente, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 343 (trezentos e quarenta e três) porções de cocaína e 84 (oitenta e quatro) porções de Cannabis sativa L. (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 22/23, laudo de constatação provisória a fls. 49/51 e exame químico toxicológico a fls. 147/149.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima indicadas, WESLEY HENRIQUE MARTINS DA SILVA REGO, LUIZ PAULO DE ALVARENGA MOREIRA e FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA E SILVA, supostamente, teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas.

O réu WESLEY HENRIQUE MARTINS deu-se por notificado, ao comparecer espontaneamente aos autos por intermédio de defensor constituído (fls. 203/204 e fls. 289), oferecendo defesa prévia a fls. 266/271.

O acusado FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA E SILVA deu-se por notificado, ao comparecer espontaneamente aos autos por intermédio de defensora constituída (fls. 233/234), oferecendo resposta preliminar a fls. 275 e fls. 276/278.

LUIZ PAULO DE ALVARENGA MOREIRA foi notificado a fls. 202 e ofereceu defesa prévia a fls. 265 por intermédio de defensor nomeado (fls. 255).

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (fls. 292/293).

Os réus foram citados e intimados para comparecer à audiência. Durante a instrução (fls. 358/361), realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa arroladas pelo réu WESLEY, uma testemunha de defesa arrolada pelo réu FERNANDO, bem como foram os réus interrogados, sendo todos os depoimentos gravados pelo sistema de captação audiovisual.

Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. A defesa do réu LUIZ PAULO requereu a absolvição, diante da ausência de provas da autoria. A defesa do réu FERNANDO pleiteou a absolvição do acusado, ante a falta de prova da autoria e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da Lei de Drogas. A defesa do réu WESLEY, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com relação aos crimes imputados, ante a falta de provas da autoria.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal há de ser julgada parcialmente procedente.

Finda a instrução processual, restou comprovado - de forma estreme de dúvida - apenas a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput e 37, ambos da Lei n.º 11.343/06, respectivamente, pelos réus WESLEY e LUIZ PAULO.

A materialidade dos delitos supracitados encontra-se provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação provisória (fls. 49/51, 104/106), exame químico-toxicológico (fls. 147/149) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria de igual forma restou cabalmente comprovada.

Em interrogatório judicial, o réu WESLEY HENRIQUE MARTINS disse que tem 21 anos, é amasiado, tem três filhos, trabalhava com seu sogro com funilaria, estudou até o primeiro colegial, já foi condenado por tráfico de drogas. Quanto aos fatos que lhe foram imputados, negou sua autoria, esclarecendo que as drogas apreendidas nos autos não são suas. Não soube dizer quem era o responsável pelas drogas encontradas na residência, pois estava morando em Taubaté na casa de seu sogro com sua mulher e filhos. Disse que fazia dois meses e pouco que se mudou de Caçapava e passou a morar na casa de sua mulher. Admitiu que deixou alguns bens no imóvel de Caçapava, pois não cabia tudo na casa de sua mulher em Taubaté. Fazia uns dois meses e pouco que não voltou mais no Pinus do Iriguassu. É verdade que já foi gerente do Pinus, mas foi preso, pagou sua pena e depois mudou de vida. Não sabe como o entorpecente apareceu no imóvel onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Disse que a casa estava com a fechadura aberta e acredita que as pessoas podem ter entrado no

local e guardado as drogas na residência. Não conhece os demais réus Luiz Paulo e Fernando. Negou a autoria e a prática de ambos os delitos. Quanto ao documento do plano odontológico apreendido durante as buscas, respondeu que ele se refere ao dia em que sua mãe o levou ao dentista após quebrar o dente, mas jamais retornou ao dentista. É verdade que depois que saiu de Caçapava, a polícia começou a invadir seu imóvel e bagunçar o local. Tal residência se localiza no Pinus II, em Caçapava. Depois o interrogando ser colocado em liberdade e do nascimento de seu filho, passou a viver honestamente e trabalhar. Declarou, por fim, que não tem relação com os fatos que lhe foram imputados e que as drogas não eram suas, reafirmando que não tem amizade ou relacionamento com os demais réus.

Em interrogatório extrajudicial (fls. 13), LUIZ PAULO DE ALVARENGA MOREIRA disse que "estava encerrando seu turno de "olheiro" quando foi abordado pelos Policiais, questionado o que seria "olheiro" disse que ganha R\$ 200,00 (duzentos reais), sendo R\$ 100,00 (cem reais) de cada "biqueira" para ficar no topo do morro de acesso ao bairro Pinus do Iriguassu I para avisar com um rádio HT se viaturas policiais chegam e se entram carros suspeitos; Que o turno é de 12 (doze) horas; Que não quer declinar o nome das pessoas que lhe contrataram para "trabalhar"; Que Fernando estava lhe auxiliando".

Ao ser interrogado em juízo, LUIZ PAULO DE ALVARENGA MOREIRA declarou que tem 31 anos, é solteiro, tem filhos, é barbeiro e faz serviço de construção civil, possui o ensino médio incompleto, já foi condenado por tráfico, associação e furto. Quanto aos fatos, admitiu que uma viatura da Polícia Civil descaracterizada o abordou na posse de um rádio de comunicação e que, no dia, estava na função de olheiro, porém, esclareceu que não conseguiu avisar ninguém já que sua prisão foi muito rápida. Quanto a Fernando, disse que ele parou no local alguns minutos da abordagem, mas, nesse dia, estava totalmente sem condição de andar diante do estado de embriaguez e drogadição; Fernando permaneceu uns 30 a 40 minutos no local e crê que ele costuma ir ao local para comprar drogas e levar reciclagem em um depósito, porém, esclareceu que Fernando não ia substituir o interrogando na função de olheiro, não sendo verdade que disse aos policiais que Fernando o substituiria. Indagado sobre o teor de seu interrogatório extrajudicial, respondeu que não disse ao delegado em seu interrogatório que Fernando estava no local para auxiliá-lo. Ponderou que foi convidado a trabalhar como olheiro por uns meninos em razão de sua dependência química e que não existia preço estipulado; no entanto, não pode dizer o nome dos meninos que o convidaram, pois isso compromete sua integridade física. Asseverou que não estava associado ao tráfico com os demais réus, esclarecendo que Fernando estava no local por acaso e de passagem. Quanto a Wesley, disse que não o conhece e que não está associado a ambos os réus. Não trabalhava rotineiramente para nenhuma das biqueiras do Pinus, esclarecendo que estava trabalhando no dia para elas apenas ocasionalmente. Conhecia Fernando como Alemão, reafirmando que não sabe o motivo pelo qual ele parou no local. Lembra-se que Fernando passou e depois voltou alcoolizado e sentou no chão molhado, sendo preso uns trinta minutos depois sem qualquer condição de conversar. Ao menos três vezes trabalhou de radinho. O interrogando não estava na venda de drogas no dia.

Em interrogatório extrajudicial (fls. 09), o réu FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA E SILVA esclareceu que "estava na hora errada e no lugar errado, que foi até o local para comprar drogas no momento em que a Polícia chegou e abordou, que quem estava com o rádio era o Luiz Paulo".

Durante interrogatório judicial, o acusado FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA E SILVA disse que tem 33 anos, é solteiro, tem um filho, possui o segundo grau completo, trabalha como carreteiro, não tem informações se responde a outros processos. Quanto aos fatos, disse que na data dos fatos foi buscar a droga; nesse contexto, subiu o morro do Pinus, comprou a droga, uma pinga e, para não descer o morro, diante do estado de embriaguez, parou seu carrinho, sentou na grama e ficou no local, até ser preso pela polícia. Confirma que Luiz Paulo foi preso na posse de um rádio, mas não é verdade que estava auxiliando Luiz Paulo na função de olheiro. Esclareceu que parou no local por acaso, pois estava bêbado e não conseguiria descer o morro com o carrinho. Não é verdade que iria substituir Luiz Paulo na função de olheiro, pois trabalhava com reciclagem e não tinha a menor condição

física de fazê-lo devido ao seu estado de embriaguez. Apesar de ter sido colocado no papel, não é verdade que iria substituir Luiz Paulo. Não conhece Wesley, embora já ouviu falar de sua pessoa e de seu apelido. Asseverou que mora no Jardim Panorama e costuma ir ao Bairro do Pinus para buscar drogas. Disse aos policiais que estava no local e horário errado, pois é dependente químico. Nunca ouviu dizer que Wesley é traficante. Na segunda vez que foi preso, não estava com rádio. Sua residência no jardim Panorama fica há dois quilômetros do local onde foi preso no Pinus.

O investigador de polícia REGIS FERNANDO GOMES DE TOLEDO, em juízo, disse que foram dar cumprimento a mandado de busca na casa de Wesley, o qual era suspeito da prática de um homicídio. Na data, em um sábado, ao chegarem no bairro, identificaram Luiz e Fernando trabalhando como campana, sendo que Luiz estava com um rádio HT na entrada do bairro. Ambos os réus foram abordados e colocados na viatura. Outras equipes entraram no Bairro do Pinus, onde havia várias pessoas na rotatória próxima à biqueira, onde existia uma espécie de fluxo. Foram à casa de Wesley, onde ingressaram no local, aparentemente habitado, apesar de estar com a porta aberta, o que levantou a suspeita de que alguém teria deixado o local minutos antes. Na residência, localizaram as drogas, além de um carnê de plano odontológico em nome de Wesley. Não há dúvidas de que Wesley morava naquela residência, a qual foi apontada pelo setor de investigação como de propriedade do réu. Confirma que a quantidade apreendida de drogas no imóvel foi de 84 porções de maconha e 343 papéletes de cocaína. Ratifica que havia evidências de que alguém passou na residência momento antes da incursão no local. Durante a abordagem, Fernando disse que estava na hora e local errado e que foi ao local apenas comprar droga; Luiz Paulo, de seu turno, disse que estava terminando o turno de serviço e que receberia R\$200,00 para trabalhar de olheiro para as duas biqueiras, sendo R\$100,00 de cada uma. Luiz Paulo disse informalmente que Fernando assumiria seu posto. Alguns dias depois, isto é, no dia 14, Luiz foi preso novamente trabalhando na função de campana e Fernando também foi preso na função de venda ou campana na entrada no bairro. Wesley residia na Rua três do Pinus (Rua Prefeito Osório) e não no centro da cidade, tal como constou dos autos. Acredita que Fernando não residia no Pinus; tanto Fernando quanto Luiz foram abordados no Pinus I e a apreensão de drogas foi no Pinus II na casa de Wesley. Tentaram chamar um vizinho para acompanhar as buscas, mas ninguém quis se identificar com o receio da represália do tráfico. Houve um corre-corre na esquina, próximo à rotatória, pois era dia de fluxo no bairro, mas não viram ninguém adentrar na residência de Wesley antes de incursionarem no imóvel. Deram cumprimento a mandado de busca em uma investigação de homicídio e não sabe se Wesley estava trabalhando com gerente da biqueira no dia; havia a informação de que Wesley era um dos gerentes do tráfico, bem como denúncias informais do envolvimento de Luiz Paulo e Fernando, mas não há nada que aponte a vinculação deles com Wesley. Esclareceu que é certo que, de alguma forma, Fernando e Wesley trabalham para o tráfico, mas não há evidências de que eles trabalhavam para Wesley. Reafirma que a apreensão na residência foi no Pinus II e Fernando foi abordado no Pinus I. A prisão foi por volta das 6:10 da manhã. Nunca viu anteriormente Fernando na companhia de Wesley ou Luiz Paulo. Luiz Paulo admitiu que estava de olheiro, mas não disse que seria para Wesley. Luiz Paulo disse que Fernando o substituiria, apesar deste último ter afirmado que estava ali apenas para comprar drogas. Na época, somente existiam duas biqueiras no Pinus II. Havia duas biqueiras e o campana trabalhava para duas. Luiz Paulo não mencionou nome nenhum e não chegou a apontar nenhuma das biqueiras. O setor de investigação não pode afirmar que existia vínculo entre Wesley e os demais réus Fernando e Luiz Paulo.

O policial civil DAVID SANTOS DE OLIVEIRA, em regular contraditório, confirmou que a investigação apontava que Wesley era um dos gerentes da biqueira da Rua 6 do Pinus II e que Luiz Paulo e Fernando foram presos na condição de olheiros. Luiz Paulo disse que estava terminando o turno de 12 horas e Fernando estava para assumir essa condição e que ambos receberiam R\$200,00, sendo R\$100,00 de cada biqueira; uma das biqueiras seria a da Rua 6. Ao ser indagado, Luiz Paulo disse que trabalhava para uma das biqueiras; já Fernando disse que estava no local para

comprar drogas e que foi preso por estar no local e horário errados, apesar de ali não ser o local da venda. Wesley guardava drogas em sua residência e fazia o abastecimento. Luiz Paulo e Fernando, após serem colocados em liberdade, foram presos na condição de olheiros. Na casa de Wesley havia sinais de que alguém foi avisado da chegada da polícia, pois era dia de fluxo e a movimentação na rua estava muito grande e a casa estava destrancada. No imóvel acharam, ademais, um documento de Wesley. Wesley era um dos gerentes e responsáveis por pagar os campanas no dia em que ele gerenciava. A rua 6 é do Pinus II e as drogas foram encontradas na casa de Wesley. Acredita que não houve tempo suficiente para que alguém ingressasse na casa e escondesse as drogas no local em função da chegada da polícia. No imóvel não encontraram objetos típicos de tráfico, salvo grande quantidade de drogas sobre o guarda-roupas. O local da diligência da busca vive sob a represália do tráfico de drogas e Wesley, inclusive, é investigado pelo crime de homicídio, razão pela qual ninguém se predispôs a acompanhar as buscas no imóvel. Fernando e Luiz Paulo foram presos logo no acesso ao Pinus I no ponto de campana e não perceberam que era a viatura da polícia. O cumprimento do mandado foi na casa de Wesley. O campana não recebia dinheiro de Wesley, mas sim da biqueira, não sabendo dizer o declarante quem era o gerente no dia, já que havia outros gerentes. No Pinus II e no Pinus I há duas biqueiras cadastradas, a da quadrinha (Rua 5) e da Rua 6 e apenas elas eram quem faziam o pagamento dos campanas; Wesley eram um dos gerentes da biqueira da Rua 6. Wesley, Luiz e Fernando nunca haviam sido vistos juntos nos pontos de campana e não há ligação deles com nenhuma das pessoas que operam no ponto de drogas.

JORGE DONIZETTI DA SILVA, informante da defesa de WESLEY, disse que é padrastrado do réu. Asseverou que Wesley, após cair em uma contradição no início da vida, isto é, envolver-se no tráfico, mudou-se de Caçapava, passou a trabalhar em uma oficina e residir no Bairro Areal em Taubaté na casa do sogro. Wesley mudou-se para Taubaté há dois meses e pouco e a casa onde morava em Caçapava ficou fechada e com a placa de aluguel. O depoente e a esposa estavam arrumando (reformando) este imóvel e, até aquele dia, não localizaram nada de ilícito no local. Havia uma televisão na casa que acredita o depoente ser de Wesley. Wesley deixou algumas coisas na casa, pois para onde mudou não havia espaço suficiente. Não sabe de quem eram as drogas apreendidas na residência, acreditando que elas não pertenciam ao acusado, não descartando a hipótese de alguém ter escondido o entorpecente no local, pois a casa vivia sendo objeto de incursões e invasões pela polícia.

PATRICIA DOS SANTOS, testemunha arrolada pelo réu WESLEY, disse que, na data dos fatos, presenciou uma "muvuca" na porta da casa de Wesley, mas esclarece que o réu não morava mais no local, mas sim em Taubaté, já que a casa estava para alugar. É moradora do Pinus 2, possui um comércio na localidade e, por isso, é de seu conhecimento que o imóvel de Wesley estava para alugar e que no bairro há denúncias de tráfico. Não viu ninguém fugindo da polícia. Não tem conhecimento se Wesley trabalhava. Fazia 4 ou 5 meses que Wesley não morava no local. A casa era da mãe de Wesley e estava para alugar. Quando a declarante saiu na rua a polícia já havia ingressado no imóvel e, por isso, não tem condições de responder o que houve antes disso.

Pois bem!

Quanto ao crime de associação ao tráfico, em que pese o esforço do representante ministerial, a hipótese é de absolvição dos réus, porquanto não comprovada a existência de "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os acusados para formar e organizar suas ações, previamente, destinadas à prática do tráfico de drogas. Com efeito, o policial civil REGIS FERNANDO, em depoimento prestado em juízo, disse de forma bem sincera que não havia à época dos fatos nada que apontasse a vinculação de LUIZ PAULO e FERNANDO com as informações e suspeitas de tráfico em nome de WESLEY.

Ademais, apesar do agente estatal acima mencionado entender que, de alguma forma, FERNANDO e WESLEY trabalhavam para o tráfico, por mais de uma vez respondeu a esse magistrado que não havia evidências de que ambos trabalhavam para WESLEY.

Pelo contrário, tal testemunha deixou bem claro que nunca viu anteriormente FERNANDO na companhia de WESLEY ou LUIZ PAULO. Também afiançou que, embora LUIZ

PAULO tenha admitido que estava de olheiro, em momento algum confidenciou aos agentes estatais que agia como informante da biqueira da qual WESLEY supostamente era um dos gerentes.

Além do mais, apesar de ser de conhecimento desse juízo que havia duas biqueiras no Bairro do Pinus e que os olheiros têm por hábito trabalhar para ambas, fato admitido pelo réu LUIZ PAULO, inclusive, não se pode ignorar a relevante afirmação do policial civil REGIS no sentido de que o setor de investigação desconhecia a prévia existência de vínculo associativo entre WESLEY e os demais réus FERNANDO e LUIZ PAULO.

Também foi sincera a testemunha REGIS ao afirmar que LUIZ PAULO não mencionou nome nenhum e não chegou a apontar nenhuma das biqueiras.

Em correspondência de entendimento, o policial civil DAVID também prestou, sob o crivo do contraditório, informações bem relevantes e que enfraquecem a imputação de associação ao tráfico contida na denúncia.

Com efeito, disse o agente estatal DAVID que “o campana não recebia dinheiro de Wesley, mas sim da biqueira, não sabendo dizer o declarante quem era o gerente no dia, já que havia outros gerentes”, além de ter confirmado que “Wesley, Luiz Paulo e Fernando nunca haviam sido vistos juntos nos pontos de campana” e que “não há ligação deles com nenhuma das pessoas que operam no ponto de drogas”.

Há mais.

Conquanto WESLEY fosse um dos gerentes de uma das biqueiras do bairro e de LUIZ PAULO ter admitido em seu interrogatório que estava trabalhando no dia como informante das duas, não há prova nos autos de que estavam associados de forma estável e duradoura ou se tudo não se passou de um concurso de agentes pontual e esporádico.

Lembra-se que para a caracterização do crime de associação para o tráfico é necessário que se comprove o caráter estável e duradouro da associação, não bastando para tanto a existência de mero concurso de agentes, tal como no caso em apreço.

Também não se comprovou para além de qualquer dúvida se FERNANDO, de fato, estava auxiliando LUIZ PAULO na função de olheiro das biqueiras e que assumiria o posto de trabalho em substituição ao corréu.

É importante ressaltar que, desde a fase inquisitiva, FERNANDO negou veementemente seu envolvimento nos fatos, esclarecendo que estava no local e horário errados após comprar drogas, beber e se entorpecer. Disse o réu, em resumo, que subiu o morro do Pinus, comprou a droga, uma pinga e, para não descer o morro, diante da embriaguez, parou seu carrinho, sentou na grama e ficou no local, até ser preso ocasionalmente pela polícia.

A versão de FERNANDO foi ratificada pelos policiais civis REGIS e DAVID, segundo quem o réu a todo o momento negou seu envolvimento com os fatos.

Ademais, embora haja informações de que WESLEY seja um dos gerentes da Biqueira da Rua 6, é de se considerar que o entorpecente apreendido foi encontrado em sua residência, que se localiza em local diverso e distante da prisão dos réus LUIZ e FERNANDO (Pinus I), acusados de serem os informantes das biqueiras das Ruas 5 e 6 do Pinus II. Assim, e porque ausente qualquer indício de vinculação dos réus LUIZ e FERNANDO com o réu WESLEY, conforme explanado pelos policiais civis DAVID e REGIS em juízo, não se pode presumir que os entorpecentes em questão seriam efetivamente destinados ao abastecimento pelo réu WESLEY de qualquer uma das biqueiras do Pinus, conforme quer fazer crer o d. representante ministerial.

Por fim, LUIZ PAULO, ao confessar em regular contraditório sua condição de informante do tráfico, acabou por isentar de responsabilidade FERNANDO, o que enfraquece a imputação que recai sobre sua pessoa.

Desse modo, não comprovada a existência de vínculo associativo com características de estabilidade e permanência, frágil e inconsistente é a acusação de associação ao tráfico atribuída aos réus WESLEY, FERNANDO e LUIZ PAULO.

No entanto, é de rigor a desclassificação da conduta atribuída ao réu LUIZ PAULO à figura típica do artigo 37 da Lei n.º 11.343/2006, porquanto o que se tem de concreto e comprovado nos autos pelo Ministério Público é que o acusado atuou como informante eventual para o crime de tráfico de drogas.

O próprio acusado LUIZ PAULO admitiu em seu interrogatório judicial que trabalhou como informante somente três vezes para os meninos em troca de drogas, já que é dependente químico.

Não se olvide que o tipo do artigo 37 da Lei n.º 11.343/2006 se verifica quando a colaboração é eventual, pois se é estável configura o crime de associação, afastado no caso em tela.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Recurso defensivo - PRELIMINAR - Alegação de nulidade da sentença - Inocorrência - Magistrado que condenou o réu pelo delito de tráfico de drogas em detrimento do crime de colaboração como informante - Acusado que se defende dos fatos capitulados na denúncia - Magistrado que pode atribuir definição jurídica diversa, sem modificar a descrição dos fatos, a teor do disposto no art. 383 do CPP - Precedente do STJ - MÉRITO - Absolvição - Impossibilidade - Autoria sobejamente demonstrada nos autos - Validade do depoimento dos agentes públicos - Fatos, contudo, que se amoldam ao delito de colaboração, como informante, com grupo para a prática do tráfico, conforme descritos na denúncia - Delito subsidiário que prevalece quando não demonstrados os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico - Desclassificação de rigor - Pena fixada no piso legal - Cabimento do regime inicial aberto e da substituição da pena - Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 15031064420178260536 SP 1503106-44.2017.8.26.0536, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 13/08/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/08/2019)

Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes atribuído ao réu WESLEY, não há nenhum indício de que as drogas tenham sido forjadas pela polícia civil em sua residência. Não é crível que policiais civis, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do réu no curso de investigação de um homicídio, prestar-se-iam a cometer tamanha arbitrariedade, forjando expressiva quantidade de drogas em desfavor de um inocente..

Da mesma forma, não se afigura verossímil a insinuação da d. Defesa de WESLEY de que alguém pode ter escondido as drogas no imóvel, que se encontrava aberto, diante da aproximação da polícia civil.

Ora, não faz o menor sentido um traficante correr o risco de sofrer prejuízo considerável, diante da elevada quantidade de drogas, escondendo o entorpecente justamente no imóvel objeto da busca e apreensão e de constantes incursões pela polícia civil, conforme admitido pela testemunha JORGE DONIZETE.

Ademais, é preciso ressaltar que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, policiais civis se depararam com o portão e portas destrancadas e com móveis em seu interior, além de algumas gavetas desarrumadas, o que levantou a suspeita de que o local era habitado e que alguém saiu às pressas antes da chegada dos agentes estatais.

Tudo leva a crer, portanto, que o acusado WESLEY ou alguém a ele subordinado, ao notar a presença da polícia no bairro, possivelmente avisado pelos moradores que se encontravam no fluxo, evadiu-se do imóvel, deixando os entorpecentes para trás. Tanto é verdade que, no imóvel, foram encontrados seus bens e seu documento odontológico com data recente (fls. 31).

Por fim, a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos na residência de WESLEY decorre das circunstâncias do caso concreto, notadamente das denúncias apontando o réu como um dos gerentes da biqueira existente no bairro Pinus II e da quantidade considerável de drogas encontradas no local, devendo ser considerada, ainda, a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, a saber: 343 porções de cocaína e 84 porções maconha, embaladas individualmente e prontas para a venda (fls. 22/23).

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item

5, pág. 96).

Considere-se, ainda, que “[...] não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]” (RT 729/542).

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade, bem como o dolo de traficar, impõe-se a condenação do réu WESLEY pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, em relação ao réu LUIZ PAULO constata-se que é portador de maus antecedentes, porquanto condenado em definitivo por furto nos autos do processo de nº 1501084-53.2020.8.26.0618 (vide FA e certidão, respectivamente, as fls. 306/312 e 352/356), razão pela qual majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação ao réu WESLEY, há de ser considerada a quantidade e natureza das drogas apreendidas nos autos (343 porções de cocaína, com peso de 249,8 gramas e 84 porções maconha, com peso de 201,5 gramas), com alto poder viciante, notadamente a cocaína, razão pela qual majoro as penas em 1/5 (um quinto), perfazendo o total de 06 (seis) anos de reclusão, além 600 (seiscentos) dias-multa.

A propósito: “O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos” (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).

Ainda, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

No tocante à segunda fase de dosimetria, quanto ao réu LUIZ PAULO, presente a circunstância atenuante da confissão. Presentes as circunstâncias agravantes dispostas no artigo 61, incisos I e II, alínea j do Código Penal.

O réu LUIZ PAULO ostenta birreincidência, uma das quais específica, já que condenado em definitivo por tráfico de drogas nos autos de nº 624-48.2017.8.26.0618 e pelo crime previsto no artigo 37 da Lei 11.343/2006 nos autos de nº 1501462-43.2019.8.26.0618, conforme dispõe a certidão de antecedentes de fls. 352/356.

Além disso, praticou o delito em situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a colaborar com o tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem-estar da coletividade.

Como a confissão de LUIZ PAULO foi relevante à formação da culpa, procedo à compensação de tal atenuante com a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal.

Em razão da birreincidência, uma das quais específica, procedo ao aumento da pena em 1/4 (um quarto), perfazendo o total de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Quanto ao réu WESLEY, ausentes circunstâncias atenuantes. Presentes as circunstâncias agravantes estipuladas no artigo 61, incisos I e II, alínea j do Código Penal.

WESLEY é reincidente específico, porquanto condenado em definitivo por tráfico de drogas nos autos do processo de 1500754-27.2018.8.26.0618, consoante se infere da certidão de antecedentes de fls. 347/349. Além disso, o acusado praticou o delito durante calamidade pública, decorrente da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Por tais razões, majoro a pena em 1/4 (um quarto), totalizando 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira etapa, em relação a ambos os réus, não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitivas as penas fixadas acima.

Consigno, por oportuno, que em relação ao réu WESLEY é incabível a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, pois é reincidente específico e, por óbvio, dedica-se à atividade criminosa, pois gerente de uma das biqueiras do bairro Pinus..

Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do réu WESLEY evidencia premeditação, dolo exacerbado e dedicação habitual à atividade criminosa, situações incompatíveis com o benefício em tela, aplicado exclusivamente ao traficante eventual e novato.

No que tange à inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, oportuno trazer o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 12 DA LEI 6.368/76. CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. EXCESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NEGATIVA DE MITIGAÇÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Inocorre constrangimento ilegal quando a Corte originária, entendendo que a paciente não satisfazia as exigências para a aplicação da causa de especial redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da expressiva quantidade de droga apreendida em seu poder e do fato de dedicar-se à atividade criminosa, fundamentadamente denegou a ordem, mantendo a decisão do Juízo da Execução. 2. Para concluir-se de forma diversa, ou seja, que a condenada não se dedicava à atividades ilícitas, necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório colacionado durante a instrução criminal, o que é incabível na via estreita do remédio constitucional. 3. Ordem denegada. (HC 93.680/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 03/11/2008, g.n.)". A propósito, não configura bis in idem a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento do redutor, pois o montante de droga pode e deve ser utilizado como impedimento da incidência da minorante (Nesse sentido: AgRg no HC 475615/SP, Relator Ministro FelixFischer, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, J. em 4.12.2018).

Confira-se:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR O REDUTOR. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA (...)." (STJ, HC 420904/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. em 28.11.2017).

Inexistente nos autos elementos no que tange à situação econômica dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

O réu LUIZ PAULO deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade imposta a LUIZ PAULO por restritiva de direitos, em razão da reincidência específica e maus antecedentes, o que evidencia a insuficiência da medida para prevenção e repressão do delito (CP, art. 44, II).

Deverá o réu WESLEY, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.654/07, bem como por sua reincidência específica no tráfico de drogas, iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, que é o mais adequado diante da gravidade do delito, assemelhado a hediondo.

Ademais, tenho que o tráfico de entorpecentes consiste crime que impulsiona e fomenta a prática de uma verdadeira cadeia criminosas, representando a raiz de diversos males sociais, assolando a coletividade de forma nociva e deletéria. Não é por outra razão que, no nosso sentir, o regime prisional mais gravoso (fechado) se mostra, além de recomendável, o único suficiente à devida prevenção e repressão deste nefasto delito.

Por fim, em observância a regra do artigo 387 do Código de Processo Penal (dada pela Lei n.º 12.736/12), anote-se que WESLEY não cumpriu em prisão provisória a fração de 60% (sessenta por cento) da pena no regime fechado, conforme determina o artigo 112, inciso VII da Lei de Execução Penal. Incabível, portanto, a fixação de regime mais brando. Frise-se, também, que sua colocação em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente, em razão de outro processo, cabendo ao juízo das execuções proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos. 66, inciso III, alínea a e 111, da Lei n.º 7.210/84.

Tratando-se o tráfico de entorpecentes de delito que importa risco concreto à população, quanto a WESLEY, é de rigor a observância do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, que veda a concessão de benefícios, tanto o mais porque eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos obviamente será insuficiente à reprovação e prevenção do ilícito, conforme sobejamente explicitado.

Acrescento, ainda, que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não seria viável já que a pena aplicada ao acusado WESLEY é superior a 04 (quatro) anos e porque o réu é reincidente específico.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para:

ABSOLVER os réus FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA E SILVA e WESLEY HENRIQUE MARTINS DA SILVA REGO da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

DECLASSIFICAR a conduta imputada ao réu LUIZ PAULO DE ALVARENGA para o delito previsto no artigo 37 da Lei n.º 11.343/06 e, por conseguinte, CONDENÁ-LO às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, no menor valor unitário, com correção na forma da lei;

CONDENAR o réu WESLEY HENRIQUE MARTINS DA SILVA REGO às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no menor valor unitário, com correção na forma da lei, por infração ao artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Conforme acima fundamentado, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos a ambos os réus.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei n.º 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Concedo ao réu LUIZ PAULO o direito de recorrer em liberdade, porque ausentes elementos supervenientes a concessão da liberdade provisória que autorizem a decretação de nova prisão preventiva neste momento processual (CPP, art. 312).

Nego ao réu WESLEY o direito de recorrer em liberdade, porquanto reforçados os pressupostos da prisão preventiva com a superveniência da presente condenação.

Servirá a presente sentença, por cópia assinada digitalmente, como ofício para a comunicação da condenação à unidade prisional em que recolhidos provisoriamente os réus, a fim de viabilizar a sua imediata transferência para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena corporal.

DETERMINO a restituição do televisor, marca Samsung, LACRE 0008625, tendo em vista

que não restou demonstrado que se trata de produto do tráfico de entorpecentes perpetrado pelo réu WESLEY. Expeça-se o necessário.

Os réus deverão arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual nº 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça(m)-se guia(s) de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) havendo defensor nomeado, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado nos autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA